



25 בפברואר 2024

לכבוד :

ח"כ שמחה רוטמן, יו"ר

ועדת החוקה, חוק ומשפט

הכנסת

שלום רב,

הנדון : הצעת חוק איסור הכחשת טבח ה-7 באוקטובר, התשפ"ד-2023

ביום 26.2.2024 תקיים הוועדה דיון בהצעת חוק איסור הכחשת טבח ה-7 באוקטובר, התשפ"ד-2023 (פ/4067/25) (להלן : **הצעת החוק**).

הצעת החוק מציעה להטיל עונש מאסר בן חמש שנים בגין התבטאויות המכחישות או ממעיטות את ממדי אירוע טבח השבעה באוקטובר, או בגין התבטאויות המביעות שבח, אהדה והזדהות למעשים שנעשו באותו יום נורא.

האגודה לזכויות האזרח מתנגדת להצעת החוק. להלן טעמינו :

1. **לגבי החלק הראשון של ההצעה** - נתחיל ונאמר כי ביום 7.10.2023 ביצע ארגון חמאס ביחד עם גורמים נוספים טבח נוראי באזרחי המדינה. הגם שכל פרטי הטבח טרם נחקרו, כבר עתה ניתן לומר כי הכחשתו של הטבח היא פסולה ומצערת. לצד זאת, הכלי הפלילי אינו הכלי הנכון לטפל בהכחשת הטבח, ונזק עולה על התועלת שבו, ובוודאי שלא באופן שבו הוצע.
2. יודגש כבר בראשית הדברים כי קיים קושי ממשי באיסור פלילי על התבטאויות, בפרט כאלו שאין בהם קריאה ישירה למעשה אלימות או שעולה מהן סכנה מוחשית ברמת וודאות גבוהה לנזק (השוו לאיסור על הסתה לאלימות הקבוע בסעיפים 2144 ו-3144 לחוק העונשין, תשל"ז-1977, ולאיסור על הזדהות עם ארגון טרור ועל פרסום דברי שבח למעשה טרור הקבועים בסעיפים 24(א) ו-24(ב) לחוק המאבק בטרור, התשע"ו – 2016). זאת נוכח עוצמתה של הזכות החוקתית לחופש ביטוי. נזכיר מושכלות יסוד : "חופש הביטוי נועד להגן, לא רק על דעות מקובלות ואהודות, המושמעות בתנאים של שלווה וביישוב הדעת, אלא גם – ובכך עיקר מבחנו של חופש הביטוי – על דעות חריגות, מקוממות ומכעיסות, המושמעות על רקע מאורעות מסעירים ובסגנון בוטה וצורם" (בג"ץ 2888/97 **נוביק נ' הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו**, פ"ד נא(5) 193 (1997). המקום בו נכנס המשפט הוא עת הביטוי הופך למסית, או עת הוא מבסס מציאות נורמטיבית בו טרור וגזענות הם מותרים (השוו ע"פ 24933-09-18 **טאטור נ' מדינת ישראל** (16.5.2019), פסקה 65). כלומר, ברירת המחדל היא כי התבטאויות, אף כאלו המעוררות שאט נפש, הינן מותרות, מתוך הבנה כי האמצעים הנכונים להתמודד עמן הם באמצעות דיון, חינוך והצגת טיעוני נגד, ולא באמצעות שלילת חירות.
3. הצעת החוק איננה מבוססת על מחקר המעיד על היקף תופעת הכחשת הטבח בישראל, על השביתה שקנתה לה תופעה זו בקרב ציבורים שונים, ועל האפקטיביות של אמצעים פחות דרקוניים להתמודדות עמה (כגון חינוך, הסברה, הסתייעות בהסרת תכנים מהרשתות החברתיות וכדומה). לאור זאת, ובהיעדר נתונים אלו, קשה להצדיק שלילת חירות לשנים ארוכות בשל התבטאות, חסרת רגישות ככל שתהיה.

4. בנוסף, בעידן שבו אנשים חשופים כל העת להצפה של מידע מסולף, שקרי או מניפולטיבי ברשתות החברתיות, קיים קושי של ממש להפעיל את הכלי הפלילי על כך שאנשים מפרסמים מחדש או חוזרים על מידע שגוי שהם מאמינים בטעות שהוא נכון, או שהם מפיצים אותו כי הוא בא ממקור שנראה להם אמין. לא כל אדם שהפיץ מחדש ידיעה שקרית שקיבל בקבוצת WhatsApp שעולה ממנה הכחשה של הטבח או הפחתה מחומרתו צריך להיות חשוף לחקירה פלילית.
5. לכן לעמדת האגודה לזכויות האזרח האיסור הפלילי על פרסום מכחיש, בנוסח שנבחר, אינו בא להתמודד עם נזק ודאי לערך חברתי חיוני ולכן אינו עומד במבחן התכלית הראויה.
6. בנוסף, הצעת החוק מציעה מנגנון שפגיעתו בחופש הביטוי בלתי מידתית. החוק אינו כולל מנגנונים אשר מוודאים כי רק התבטאויות חמורות במיוחד יופללו, תוך בחינת היסוד הנפשי, ההסתברות כי ההתבטאות תוביל לפגיעה, ויצירת מנגנון פרוצדורלי שימנע הפללת יתר.
7. עיון בכותרת הצעת החוק ובניסוח סעיפיה השונים מורים כי נכתבה בהשראת חוק איסור הכחשת השואה, תשמ"ו – 1986 (להלן: **חוק איסור הכחשת השואה**). נתחיל ונאמר שהשואה הייתה אירוע ייחודי, שייתכן ומחייב התמודדות ייחודית. חוק איסור הכחשת שואה חוקק לפני חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, הוא נהנה משמירת דינים וגם מעולם לא הורשע אדם על בסיסו, ולכן אין כל פסיקה שעוסקת בחוקתיות החוק. בכל מקרה, החוק המוצע קיצוני בהרבה מחוק איסור הכחשת שואה.
8. סעיף 2 להצעת החוק אוסר על הכחשת טבח השבעה באוקטובר:
- המפרסם, בכתב או בעל פה, דברים המכחישים את טבח ה-7 באוקטובר, או ממעיטים את ממדיהם, דינו – מאסר חמש שנים
9. סעיף 2 לחוק איסור הכחשת השואה, לעומת זאת, אוסר על הכחשת השואה רק מתוך כוונה להגן על מבצעי הפשעים:
- המפרסם, בכתב או בעל פה, דברים המכחישים את המעשים שבוצעו בתקופת השלטון הנאצי ושהם פשעים כלפי העם היהודי או פשעים כלפי האנושות, או ממעיטים את ממדיהם, **בכוונה להגן על מבצעי הפשעים הללו או להביע להם אהדה או הזדהות, דינו – מאסר חמש שנים.**
- (ההדגשה איננה במקור)
10. סיפא זו בעלת חשיבות מירבית. יסוד נפשי של כוונה להגן על מבצע הפשע או להביע להם אהדה יש בה לצמצם בצורה ניכרת את הפגיעה בחופש הביטוי. בהצעה הנדונה אפילו אין סיפא דומה.
11. בנוסף, בניגוד להצעת החוק, מבהיר חוק איסור הכחשת השואה כי דיווח על התבטאות אסורה אשר נעשה באופן "נכון והוגן", לא יראה כעבירה. בהיעדר סעיף דומה בהצעת החוק, אפילו דיווח עיתונאי המטיל ספק בגרסת השלטון לגבי מצב העניינים **העובדתי** ביחס לטבח השבעה באוקטובר עלול להיחשב כהמעטה בממדי הטבח, להיתפס כעבירה פלילית חמורה.
12. בנוסף, סעיף 5 לחוק איסור הכחשת שואה מתנה הגשת כתב אישום בגין התבטאות המכחישה את השואה או מביעה אהדה למבצעה באישור או הסכמת היועצת המשפטית לממשלה. גם סעיף מעין זה אינו קיים בהצעת החוק שבנדון והדבר יוביל להפללת יתר.

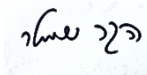
13. בהיעדר יסוד של כוונה, ומנגנונים מאזנים נוספים, מדובר בעבירה בעלת ממד רב של עמימות, שעלולה להפליל אפילו מי שמבקש לשים את הטבח בקונטקסט מסוים, שסותר את הנרטיב של השלטון. הרחבת המגבלות הפליליות על חופש הביטוי באופן המוצע הינה מסוכנת וקיצונית. קיים חשש ממשי כי החוק כפי שהוא יוביל לאפקט מצנן על חופש הביטוי, באופן בלתי מידתי, ושאיננו נדרש.

14. **לגבי החלק השני של הצעת החוק** – חלק זה מבקש לקבוע כי פרסום דברים של שבח, אהדה או הזדהות למעשים שנעשו בידי חמאס באירועי ה-7 באוקטובר ובהמשך להם הוא עבירה פלילית שדינה 5 שנות מאסר. חלק זה בא להרחיב בצורה לא מידתית את האיסור הקיים כבר בחוק המאבק בטרור. לפי סעיף 24 (ב)(2) לחוק המאבק בטרור, "המפרסם דברי שבח, אהדה או עידוד למעשה טרור, תמיכה בו או הזדהות עמו, ועל פי תוכנו של הפרסום והנסיבות שבהן פורסם יש אפשרות ממשית שיביא לעשיית מעשה טרור" – דינו 5 שנות מאסר. מכאן שהצעת החוק באה לבטל את הרכיב ההסתברותי. בכך יש פגיעה לא מידתית בחופש הביטוי, כפי שכבר הוסבר בדיוני הוועדה בשבוע שעבר ביחס הצעת חוק המאבק בטרור (תיקון – הזדהות עם מבצע עבירת טרור מסוג המתה), התשפ"ג–2023 של ח"כ צבי סוכות.

15. הרכיב ההסתברותי הוא חלק מהאיזון שנקבע בחוק, ומטרתו למנוע הפללת יתר של ביטויים שנאמרים באופן שאינו מסכן ערכים חברתיים חיוניים. החוק הפלילי נועד להתמודד עם החשש מהסתה לביצוע מעשי טרור, ובהיעדר רכיב הסתברותי, האיסור הפלילי מתרחב בצורה המסכנת את חופש הביטוי ונוקו עולה על התועלת.

16. לאור המכלול, אין מקום לקידום הצעת החוק האמורה.

בכבוד רב ובברכה,



הגר שחטר, עו"ד

העתק:

מר גור בליי, היועץ המשפטי של הוועדה

חברי הוועדה